

列入《国家重点保护野生植物名录》的野生植物，根据其保护级别分别适用相应的株数、立木蓄积标准；第三款对未列入名录的古树名木，在株数、立木蓄积标准上未进行明确，而是规定以“根据涉案树木的树种、树龄以及历史、文化价值等因素，综合评估社会危害性，依法定罪处罚”。第一款的定罪量刑标准延续了2000年破坏森林资源解释的做法，而第三款则与之前完全不同，未明确数量标准，也非传统意义上的情节标准，仅给出“综合评估”的裁判方法，该种入罪量刑方式一般用于兜底条款，该法条的适用对法官来说是一种挑战。

（二）综合评估社会危害性的理解

1. 罪责刑相适应原则

经梳理法律法规，有三份司法解释、一份意见和三份批复在条款中明确提到“综合评估社会危害性”。①考察以上文件相关条款内容和文件出台的时机可知，“综合评估社会危害性”是在法律适用与现实行为量刑不匹配情况下的兜底说法，如《最高人民法院、最高人民检察院关于涉以压缩气体为动力的枪

①指2023年破坏森林资源解释、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理破坏野生动物资源刑事案件适用法律若干问题的解释》；《最高人民法院、最高人民检察院关于依法惩治涉枪支、弹药、爆炸物、易燃易爆危险物品犯罪的意见》；《最高人民法院、最高人民检察院关于适用〈中华人民共和国刑法〉第三百四十四条有关问题的批复》《最高人民法院、最高人民检察院关于涉以压缩气体为动力的枪支、气枪铅弹刑事案件定罪量刑问题的批复》《最高人民法院、最高人民检察院关于利用网络云盘制作、复制、贩卖、传播淫秽电子信息牟利行为定罪量刑问题的批复》。

支、气枪铅弹刑事案件定罪量刑问题的批复》是在“天津大妈摆打气球摊获刑案”^①发生后出台的,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理破坏野生动物资源刑事案件适用法律若干问题的解释》相关法条则是在“河南大学生掏鸟案”^②“防御性捕猎案”^③等类似案件发生后出台。

2. 评判标准为价值标准

从该条款“根据涉案树木的树种、树龄以及历史、文化价值等因素”的表述可知,可从三个维度对被告人行为的社会危害性进行评估:一是树木树种;二是树龄;三是树木的历史、文化价值。以上三个因素与前述条款的数量标准完全不同,其目的是使得该类犯罪的定罪量刑的标准更加符合罪责刑相适应原则的要求,以破除数量标准与个案不相适应的问题,且该价值标准应当贯穿于案件审理的始终。需要注意的是,此评判标准中的“以及”理解为“且”的关系更符合立法本意,即要综合评估三大因素,才能认定在社会危害性上是否达到第二条第一款的程度,达到相当的危害程度时,被告人的行为才构成犯罪,否则其行为不构成刑事犯罪,可由行政法规调整。

二、2023年破坏森林资源解释第二条第三款的司法适用

(一) 涉案树木未被列入《国家重点保护野生植物名录》

该款规定情形的认定,属于法律事实判断。《国家重点保护野生植物名录》共列入国家重点保护野生植物455种和40类,包括国家一级保护野生植物54种和4类,国家二级保护野生植物401种和36类。司法实践中,涉案树木是否列入该名录,不属于证明事项,只需客观上已经列入即可。本案中,涉案树木均为榿木,未在《国家重点保护野生植物名录》中,符合该条要求。

(二) 认定涉案树木保护等级——“司法鉴定+地方规定”

因涉案树木未被列入《国家重点保护野生植物名录》,故对涉案树木是否

^①参见“中国青年报”微信公众号,
<https://mp.weixin.qq.com/s/2peYTNk35hvi51s0-J0bg>,2025年4月16日访问。

^②(2015)新中刑一终字第128号刑事裁定书,载中国裁判文书网,2025年4月16日访问。

^③参见中华人民共和国最高人民检察院网站,
https://www.sp.gov.cn/lyj/202305/t20230513_613939.shtml,2025年4月23日访问。

属于古树名木并不明确，应当对涉案树木的情况进行鉴定。根据《城市绿化条例》第二十四条规定，百年以上树龄的树木，稀有、珍贵树木，具有历史价值或者重要纪念意义的树木，均属古树名木。《古树名木保护条例》第二条规定：“本条例所称古树，是指树龄100年以上的树木，不包括人工培育、以生产木材为主要目的的商品林中的树木。本条例所称名木，是指具有重要历史、文化、科学、景观价值或者具有重要纪念意义的树木。”由以上文件规定可看出，古树的树龄一般需达到100年以上，名木则具有一定的历史、文化价值。本案中，经具有鉴定资质的鉴定机构鉴定，认为被查获的13株榿木树中有3株树龄在100年以上，均为白花榿木。

关于古树的等级，各地省级林业部门制定了相关条例对古树名木的等级进行明确，具体规定不一。^①因树木被侵害对当地的生态环境影响最大，所以依照涉案树木所在地对树木等级的规定进行定性最为妥当，故涉案树木中有3棵树是三级保护古树。

（三）认定涉案树木价值——“专家意见+法院评判”

因本案涉案树木树龄在100年以上，从其树龄上难以判断其真实价值，对其历史、文化价值进行评判确有必要且极为重要。司法实践中，如何对涉案树木历史、文化价值进行评估主要做法有两种：一是采集多名证人证言，由法院综合案情进行评判；二是请权威部门、有专门知识的人对历史、文化价值作出评判。当前未有司法鉴定中心可对涉案树木的历史、文化价值进行鉴定，根据2021年施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百条规定，法院可指派、聘请有专门知识的人就涉案树木的历史、文化价值出具报告。本案中，浮梁法院同时采取三种方式：一是向省级林业主管部门发函询问；二是要求本案委托的司法鉴定中心的鉴定人员出庭说明；三是邀请有专门知识的人员出庭说明。以上获得的证据具有合法性、关联性、可靠

^①如《北京市古树名木保护管理条例》第二条规定，凡树龄在三百年以上的树木为一级古树；其余的为二级古树。《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第八条规定，名木以及树龄在三百年以上的古树为一级保护；树龄在一百年以上三百年以下的古树为二级保护。

性。经法院综合评判，涉案树木中有3株具有一定历史、文化价值，故被告人的行为构成犯罪。

（四）适用量刑规则——刚柔并济

司法实践中，针对未被列入《国家重点保护野生植物名录》的古树名木的危害行为，入罪后该如何量刑，在明确树木等级的前提下，非最高等级的古树可参照国家二级保护野生植物的标准进行量刑；最高等级的古树则参考国家一级保护野生植物的标准进行量刑。同时结合涉案树木的历史、文化等价值，除非涉案名木具有特别重大意义，一般情况下应当以第一档刑罚量刑为宜。本案中，参考国家二级保护野生植物需二株以上才入罪，涉案榿木仅三株达到三级保护，应当适用第一档量刑进行处罚，即在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金范围内量刑。同时综合考量涉案榿木已保护性就地栽种并全部成活，且被告人自愿退缴违法所得，故对其依法适用缓刑，体现了人民法院在助力当地生态资源高水平保护的同时，刚柔并济地适用刑事政策与原则。

综上，针对未被列入《国家重点保护野生植物名录》的古树名木的刑事案件审理，既要保护生态环境，又要贯彻罪责刑相适应的基本原则。

编写人：江西省浮梁县人民法院 吴丹

江西省景德镇市中级人民法院 罗慧青

(五)其他

55

转让方未取得采矿许可证的采矿权转让合同无效

——某实业公司诉淡某某等采矿权转让合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

郑州铁路运输中级法院(2023)豫71民终38号民事判决书

2. 案由: 采矿权转让合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某实业公司

被告(被上诉人): 淡某某、某矿业分公司

被告(上诉人): 某矿业公司

【基本案情】

2018年3月28日和9月30日,淡某某代表某矿业分公司与某实业公司签订矿山转让合同及补充协议,约定某矿业分公司将其位于巩义市某镇某处400亩地的露天铝矿生产经营权转让给某实业公司,合同约定总价款1768万元。某实业公司向某矿业分公司委托人淡某某支付首笔转让资金100万元,某矿业分公司在收到该款项后20个工作日内完成矿山开工验收工作,以使某实业公司能按期进场正常生产。若某矿业分公司未能按期完成验收、某实业公司未能正常生产,某矿业分公司需退回某实业公司100万元的转让款并承担损失。2018年

10月8日，淡某某出具收据载明收到某实业公司支付的100万元矿山转让款。

某矿业分公司系某矿业公司依法设立并领取营业执照的分支机构。某矿业分公司、某矿业公司均未依法取得案涉露天铝矿的采矿权。

因某实业公司未能按期进场正常生产，双方虽经多次沟通，未能达成一致。现某实业公司请求法院判令：(1)确认某实业公司与某矿业分公司签订的矿山转让合同及矿山转让合同补充协议无效；(2)判令三被告退还100万元及利息（以100万元为基数，自2018年11月8日起至实际付清之日止，按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率，参照逾期罚息利率标准计算）。

【案件焦点】

1. 在转让方未取得采矿许可证的情况下，与受让方签署转让采矿权合同的效力应如何认定；2. 采矿权转让合同被确认无效后的法律后果如何。

【法院裁判要旨】

郑州铁路运输法院经审理认为：《中华人民共和国矿产资源法》第三条规定，开采矿产资源必须依法申请取得采矿权，采矿权不得买卖、出租，不得用作抵押。《探矿权采矿权转让管理办法》第三条规定：“除按照下列规定可以转